

(35)

MOHD FADZLI BIN MUSA KUTTY

lwn.

ROHAILAH BINTI MOHAMAD IDRUS

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin Dato' (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 10 Mac 2020 bersamaan 15 Rejab 1441H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-074-0087-2018]

[Rayuan Terhadap Perintah Pengkomitan Di Bawah Seksyen 151 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tidak Diwakili.

Peguam Syarie Responden : Tidak Diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu pada terhadap keseluruhan keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 3/7/2018 di dalam Kes Permohonan No. : 10400-074-0795-2017 yang telah mengeluarkan penghakiman sepertimana berikut –

- i. *Mahkamah meluluskan Permohonan Pengkomitan Pemohon berdasarkan subperenggan 151 (1)(b)(aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*

- ii. *Mahkamah memerintahkan bahawa Responden disabitkan telah melanggar Perenggan 3 Penghakiman Persetujuan bertarikh 18/7/2017.*
- iii. *Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah dikomitkan ke Penjara selama tiga (3) mulai hari ini.*

[2] Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 3/7/2018. Perayu juga telah mengemukakan Alasan Rayuan pada 2/1/2019 yang mengandungi sepuluh (10) Alasan Rayuan alasan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Rekod Rayuan bertarikh 31/1/2019 halaman 122 – 124.

Fakta Kes

[3] Perayu dan Responden telah bernikah pada 20/12/2008 dan telah bercerai pada 14/2/2017. Hasil perkahwinan tersebut, mereka telah dikurniakan dengan tiga (3) orang anak lelaki. Pada 18/7/2017, Mahkamah Tinggi Syariah Selangor melalui kes Saman No. : 10400-028-0338-2017 telah mengeluarkan Penghakiman Persetujuan Hadhanah sepertimana berikut –

- i. *Mahkamah memerintahkan hak jagaan anak (hadhanah) bagi anak yang bernama –*
 - a. *Mohamad Faris Rayyan Bin Mohd Fadzli (No. Mykid : 100103-16-0225)*
 - b. *Mohamad Raef Rifqi Bin Mohd Fadzli (No. Mykid : 130407-16-0061)*
 - c. *Anas Bin Mohd Fadzli (No. Mykid : 161004-10-1173)**hendaklah diberikan kepada Plaintiff (ibu)*

- ii. *Mahkamah memerintahkan bahawa hak lawatan anak-anak tersebut hendaklah diberikan kepada Defenden (bapa) pada bila-bila masa yang munasabah dengan makluman kepada pihak Plaintiff (ibu).*
- iii. *Mahkamah memerintahkan bahawa hak melawat dan bermalam pada hujung minggu hendaklah diberikan kepada Defenden iaitu dua kali dalam sebulan iaitu pada hari Jumaat petang sehingga dikembalikan pada hari Ahad petang dengan makluman terlebih dahulu sehari sebelum perjumpaan kepada pihak Plaintiff dan / atau wakilnya. Bagi anak ketiga, Defenden hendaklah diberikan hak lawatan tanpa bermalam pada hujung minggu sebanyak dua kali dalam sebulan, sehingga anak-anak tersebut mencapai usia yang dipersetujui oleh pihak-pihak untuk bermalam.*
- iv. *Mahkamah memerintahkan Plaintiff dan Defenden hendaklah bersikap tolak ansur dan saling bekerjasama berkenaan hak bersama anak-anak tersebut dengan meletakkan kebajikan (kemaslahatan) anak-anak tersebut sebagai yang paling afdhal dan terutama.*

[4] Pada 31/10/2017, Responden telah memfailkan permohonan untuk mendapatkan kebenaran untuk menguatkuasakan penghakiman persetujuan tersebut berdasarkan seksyen 151 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETMMSS 2003] kerana melanggar terma di perenggan 3 Penghakiman Persetujuan tersebut. YA Hakim Bicara pada 12/12/2017 telah memberi kebenaran terhadap permohonan tersebut dan suatu Notis Tunjuk Sebab telah dikeluarkan kepada Perayu dan berjaya diserahsampaikan kepada Perayu pada 7/1/2018.

[5] Perayu telah memfailkan Affidavit Pembelaan terhadap Notis Tunjuk Sebab tersebut pada 12/3/2018. Manakala Responden pula telah memfailkan Affidavit Balasan pada 16/5/2018. Tiada hujahan difailkan oleh kedua-dua pihak dan pada 3/7/2017 YA telah mengeluarkan keputusan sepertimana perenggan 1 (i-iii). Akibat tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 3/7/2018 terhadap keseluruhan keputusan tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[6] Sebelum kami membuat ulasan berhubung dengan rayuan ini, kami dapati bahawa perjalanan prosiding kes pengkomitan, Kes Permohonan No. : 10400-074-0795-2017 sedikit tidak teratur selepas Notis Tunjuk Sebab (NTS) dikeluarkan di mana setelah menerima NTS, Responden (Perayu) telah memfailkan Affidavit Pembelaan terhadap NTS tersebut, kemudian Pemohon (Responden kes rayuan ini) pula memfailkan Affidavit Balasan.

[7] Merujuk kepada kes *Shah Christirani Binti Azhar lwn. Othman Bin Talib*, Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-036-0006-2014, di mana Panel Rayuan Syariah Negeri Selangor telah mengesahkan ulasan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di dalam kes *Othman Bin Talib lwn. Shah Christirani Binti Azhar*, Kes MTS Selangor Permohonan No : 10300-036-0414-2012 berhubung dengan tatacara pengkomitan di bawah seksyen 151 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang antara lain menerangkan bahawa sekiranya Responden hendak membela dirinya secara lisan, maka Hakim Bicara hendaklah menjalankan siasatan terhadap Responden secara “*inquisitorial*”. Namun begitu, Hakim Bicara berdasarkan kuasa budi bicaranya boleh membenarkan Responden

disoal oleh Pemohon dan / atau Peguamnya sendiri. Sekiranya Responden ingin memfailkan pembelaannya secara bertulis atau melalui Afidavit Pembelaan maka Hakim Bicara boleh membenarkannya untuk disoal-balas dan disoal-semula oleh pihak-pihak termasuklah Hakim Bicara itu sendiri.

[8] Bagi prosiding kes pengkomitan tersebut, YA Hakim Bicara telah membenarkan Afidavit Balasan difailkan oleh Pemohon. Tindakan ini telah jelas menunjukkan bahawa YA Hakim Bicara **terkeliru** dalam mengendalikan prosiding kes pengkomitan tersebut sedangkan panduan dan tatacara telah diberikan di dalam kes *Othman Bin Talib lwn. Shah Christirani Binti Azhar* yang telah diputuskan terlebih dahulu iaitu pada 11/7/2013, manakala keputusan Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah mengesahkannya pada 5/11/2014.

[9] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami akan rangkumkan sepuluh (10) Alasan Rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu kepada satu (1) isu sahaja, iaitu sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf mensabitkan Perayu telah melanggar terma di perenggan 3 Penghakiman Persetujuan bertarikh 18/7/2017 dengan mengkomitkan Perayu ke penjara selama 3 hari.

[10] Merujuk NTS pada halaman 22 Rekod Rayuan, kami dapati bahawa satu NTS telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor kepada Perayu bertarikh 4/1/2018 untuk menunjuk sebab mengapa Perayu tidak patut dikomitkan ke penjara kerana mengingkari Perintah Mahkamah bertarikh 18/7/2017 di perenggan 3 dalam Kes Saman No. : 10400-028-0338-2017.

[11] Berdasarkan NTS tersebut, kami dapati bahawa NTS tersebut langsung tidak menyatakan tempoh masa pelanggaran dan bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Perayu. Merujuk kepada kes **Baidura Binti Bahari Lwn. Ahmad Haidzir Bin Anuwar Dan Hamidah Binti Bakar**, Kes Rayuan No. : 10000-036-0058-2015, Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor menyatakan bahawa -

“Kami hanya menemui fakta berkenaan perenggan (g) yang telah diulas Hakim Bicara di dalam Afidavit Tambahan Responden 1 (Amad Haidzir Bin Anuwar) bertarikh 29/3/2013 (m.s 68-73 Rekod Rayuan) sahaja. Selain daripada itu, tidak terdapat apa-apa fakta berkenaan pelanggaran perenggan (g) di mana-mana kertas pliding Responden, di dalam Notis Tunjuk Sebab (m.s 103-105 Rekod Rayuan), di dalam Nota Keterangan (ketika prosiding soal utama, soal balas dan soal semula) (m.s 121-131 Rekod Rayuan) dan di dalam penghujahan bertulis Responden (m.s 133-149 Rekod Rayuan). Sedangkan apa yang menjadi kewajipan kepada Perayu hanyalah untuk menjawab apa-apa fakta di atas pengetahuannya yang telah dinyatakan di dalam Notis Tunjuk Sebab sahaja.

Kami bersetuju dengan Perayu bahawa, di mana-mana bahagian di dalam Notis Tunjuk Sebab tersebut tidak ada dinyatakan berkenaan ulasan Hakim Bicara ketika mensabitkan Perayu telah melanggar perenggan (g) Perintah Persetujuan Bersama.

Ketiadaan apa-apa fakta yang tersurat di dalam Notis Tunjuk Sebab berkenaan pelanggaran perenggan (g) Perintah Persetujuan Bersama telah menyebabkan Perayu telah dinafikan haknya untuk menjawab dan menunjukkan sebab atau alasan pelanggaran itu berlaku. Kegagalan Perayu untuk menjawab atau menunjukkan sebab berkenaan fakta tersebut tidaklah boleh dibebankan ke atas Perayu kerana ternyata kewujudan fakta pelanggaran perenggan (g) adalah di luar pengetahuannya pada setiap masa material sepanjang prosiding perbicaraan berlangsung di Mahkamah Bicara “

[12] Oleh yang demikian kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf mengeluarkan NTS tanpa apa-apa fakta atau tempoh masa pelanggaran serta bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Perayu terhadap terma di perenggan 3 di dalam NTS tersebut.

[13] Manakala merujuk kepada perenggan 3 Penghakiman Persetujuan bertarikh 18/7/2017, kami dapati bahawa Penghakiman tersebut tidak menyatakan hujung minggu yang mana Perayu diberikan hak untuk melawat dan bermalam dengan anak-anak tersebut sebaliknya hanya dinyatakan dua kali sebulan iaitu pada hari Jumaat petang sehingga dikembalikan pada hari Ahad petang dengan syarat memaklumkan kepada Responden dan / atau wakilnya sehari sebelum pelaksanaannya.

[14] Berdasarkan perenggan 3 Penghakiman tersebut, bagi mensabitkan Perayu melanggar terma di perenggan 3 tersebut, kami berpendapat ada **3 elemen** yang perlu diperhalusi dan dipertimbangkan oleh YA Hakim Bicara iaitu –

- i. Perayu melanggar bilangan untuk hak melawat dan bermalam dengan anak-anak iaitu melepasi 2 kali sebulan;
- ii. Perayu melawat dan bermalam dengan anak-anak di luar waktu yang ditetapkan iaitu Jumaat petang sehingga Ahad petang; dan
- iii. Pemakluman kepada Responden dan / atau wakilnya kurang sehari sebelum pelaksanaan.

[15] Elemen-elemen di atas adalah sangat penting untuk memastikan bahawa dakwaan tersebut memenuhi kehendak undang-undang dan Hukum Syarak. Pada hemat kami, pelanggaran kesemua elemen-elemen tersebut sahaja membawa maksud berlakunya pelanggaran terma di perenggan 3 Penghakiman tersebut.

[16] Merujuk kepada Afidavit Sokongan bertarikh 31/12/2017 yang difailkan oleh Responden semasa memohon perintah kebenaran pengkomitan (Rujuk halaman 4-21, Rekod Rayuan), Responden hanya membangkitkan kejadian yang berlaku pada 27/10/2017 iaitu –

- i. Perayu hanya memaklumkan pada 27/10/2017 jam 6.16 petang tentang kehadirannya untuk menjemput anak-anak pada jam 11.00 malam lebih (hari yang sama);
- ii. Perayu ada hadir pada malam tersebut sekitar jam 11.55 malam tetapi tidak dapat mengambil anak-anak tersebut; dan
- iii. Perayu hadir semula ke rumah Responden dan menjemput anak-anaknya pulang bermalam sekitar jam 12.00 tengahari 28/10/2017.

[17] Merujuk kepada Alasan Penghakiman (halaman 107 - 108, Rekod Rayuan), YA Hakim Bicara menyatakan –

“[23] Di dalam Afidavit Sokongan Pemohon tersebut, Pemohon telah membangkitkan isu kegagalan Responden untuk memaklumkan kepada Pemohon tentang kehadirannya sehari sebelum perjumpaan dan hanya memaklumkan tentang kehadiran Responden pada petang (6.17pm) hari perjumpaan. Responden gagal mengambil anak pada hari Jumaat 27/10/2017, sebaliknya hadir jam 11.55 malam setelah Pemohon dan anak-anak tidur. Responden telah bertindak membuka pagar

rumah dan mengetuk pintu rumah Pemohon dengan sangat kuat pada 11.55 malam ketika Pemohon, anak-anak, dan ibubapa Pemohon sedang tidur.

[24] Responden telah membela dirinya melalui Afidavit Jawapan yang telah dibuat pada 12/3/2018 tanpa membawa saksi bagi menyokong pembelaannya. Isu utama di dalam kes ini adalah mengenai waktu pengambilan anak-anak tersebut oleh Responden pada 27/10/2017. Oleh kerana kejadian pada 27/10/2017 terjadi pada hari Jumaat, ia bersesuaian dengan keputusan Mahkamah mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab disebabkan keingkaran atau kecuai Responden terhadap Perenggan 3 Perintah Mahkamah bertarikh 18/7/2017 tersebut”

[18] Berdasarkan situasi tersebut, kami berpuashati bahawa isu NTS dikeluarkan adalah disebabkan kegagalan Perayu memaklumkan kepada Responden sehari sebelum melaksanakan hak lawatan dan bermalam dengan anak-anak tersebut. Kami juga berpuashati bahawa pemakluman tersebut hanya dibuat pada 27/10/2017 jam 6.16 petang untuk pengambilan anak-anak pada jam selepas 11.00 malam hari yang sama.

[19] Pada asasnya jelas Perayu telah melanggar salah satu elemen dari terma di perenggan 3 tersebut kerana gagal memaklumkan sehari awal sebelum mengambil anak tersebut pada 27/10/2017. Walaubagaimanapun, pengambilan anak-anak tersebut tidak berjaya dilakukan pada 27/10/2017, sebaliknya hanya berlaku pada keesokannya iaitu jam 12.00 tengahari 28/1/2017. Jika dilihat kepada situasi tersebut, kami dapati bahawa Perayu tidak melanggar elemen pemakluman tersebut dari terma di perenggan 3 tersebut kerana pemakluman telah dibuat pada 27/10/2017 dan pengambilan anak-anak hanya berjaya dibuat pada 28/1/2017.

[20] Kami juga dapati bahawa terma di perenggan 3 Penghakiman tersebut tidak menyatakan tentang waktu pengambilan secara khusus, sebaliknya hanya menyatakan hak Perayu untuk melawat dan bermalam dengan anak tersebut 2 kali sebulan pada hari Jumaat petang sehingga Ahad petang. Maka adalah jelas Perayu mempunyai hak tersebut dari Jumaat petang sehingga Ahad petang dengan memaklumkan sehari sebelum kepada Responden dan / atau wakilnya.

[21] Berdasarkan situasi di atas, kami berpuasahati bahawa YA Hakim Bicara gagal menilai keadaan yang telah berlaku sehingga menjadi suatu pelanggaran terhadap terma di perenggan 3 Penghakiman yang dikeluarkan tersebut. Kegagalan ini menunjukkan bahawa terdapat kekhilafan YA Hakim Bicara di peringkat awal penilaian terhadap permohonan kebenaran untuk pengkomitan dan pengeluaran NTS yang akhirnya mengakibatkan berlaku kesilapan dalam mengklasifikasikan terma perintah / penghakiman yang dilanggar.

[22] Berdasarkan ulasan yang telah dikemukakan, kami berpuasahati bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf mengeluarkan NTS kepada Perayu tanpa wujud sebarang pelanggaran kepada terma di perenggan 3 Penghakiman tersebut. Keadaan ini menyebabkan kami perlu campurtangan terhadap keputusan yang telah dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara pada 3/7/2018.

[23] Pada kesempatan ini, sukacita Mahkamah mengingatkan kepada kedua-dua pihak agar mematuhi apa-apa perintah / penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah tanpa engkar agar proses perlaksanaan perintah / penghakiman Mahkamah berjalan lancar. Mahkamah juga menasihatkan kepada Perayu dan Responden sebagai ibubapa kepada anak-anak tersebut, agar memberi kerjasama

dalam memastikan kebajikan dan kemaslahatan anak-anak tersebut terjaga tanpa halangan antara satu sama lain bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing sebagai ibu dan bapa kepada anak-anak tersebut. Hargailah kurniaan anak-anak kepada kita kerana ia adalah **AMANAHAH ALLAH** s.w.t. yang tidak ternilai.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod-Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak yang telah difailkan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

1. Rayuan Perayu ini adalah **DITERIMA**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor dalam **Kes Permohonan No. : 10400-074-0795-2017** bertarikh 3/7/2018 adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



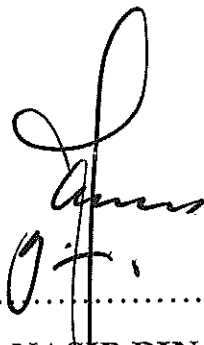
-
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor